

1500439-07.2019.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Constrangimento ilegal

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA MAJORADA NA PRIMEIRA FASE UTILIZANDO MAUS ANTECEDENTES E NA SEGUNDA A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECURSO DE LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O TÉRMINO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E A DATA DO NOVO CRIME. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. FOLHA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500439-07.2019.8.26.0022 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500439-07.2019.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Constrangimento ilegal

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2091136/2019 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2501675 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 581/19/935 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2091136 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 581/19/935 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2091136 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 581/19/935 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO LEITE

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

MARCOS ROBERTO LEITE, identificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no art. 65 da Lei das Contravenções Penais, com incidência da Lei nº 11.340/06, acusado de ter, no dia 21 de março de 2019, por volta das 18h30min, na Rua Cabo João dos Santos, próximo ao número 301,

Bairro Ribeirão, nesta cidade e Comarca, por motivo reprovável, perturbado a tranquilidade de sua ex-esposa Osana Aparecida da Silva, prevalecendo-se de relação íntima de afeto pré-existente (fls. 36/37).

Representação (fl. 07). Ratificada (fl. 45).

A denúncia foi recebida em 11.05.2020 (fl. 50).

Devidamente citado (fl. 74), o acusado, por intermédio de sua D. Defensora nomeada (fl. 77), apresentou resposta por escrito à acusação (fls. 80/81), arrolando as mesmas testemunhas.

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito, com a absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura da fase instrutória (fl. 84), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas da vítima e de uma testemunha arrolada em comum pelas partes, seguindo-se do interrogatório do acusado, tudo pelo sistema audiovisual (cf. ata de fl. 119).

Em sede de memoriais, a D. Promotora de Justiça pugnou pela aplicação do princípio da continuidade normativa-típica, condenando-se o acusado como incurso no art. 147-A do Código Penal e aplicando-se a pena do art. 65 da Lei das Contravenções Penais, por ser mais benéfica, eis que provadas autoria e materialidade delitivas, enquanto a D. Defensora pleiteou a absolvição, fundamentando-a na atipicidade da conduta, haja vista sua intenção ser apenas conversar com a vítima, não praticando o delito em tela. Por fim, teceu considerações acerca da dosimetria da pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, é imperioso destacar que a Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021 – ou seja, publicada posteriormente aos fatos narrados nestes autos – revogou expressamente o artigo 65, da Lei de Contravenções Penais, e inseriu no Código Penal o artigo 147-A, tipificando o crime de perseguição.

Em razão da revogação daquela contravenção de perturbação da tranquilidade e criação do crime de perseguição ou “stalking” no Código Penal Brasileiro, muito se tem discutido na doutrina e jurisprudência se esta alteração legislativa ensejaria o reconhecimento da abolitio criminis ou da continuidade normativo-típica.

Destaca-se que até o presente momento tem prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que a contravenção penal estaria alcançada pela abolitio criminis somente nos casos em que a conduta do agente não fosse reiterada. Isto é, tratando-se de conduta isolada, haveria o reconhecimento da revogação material do delito.

Todavia, em casos de reiteração de condutas, com acinte e por motivo reprovável, e que tenham gerado uma perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima, não haveria campo para a abolitio criminis, mas, sim, aplicação do princípio da continuidade normativo-típica. Vale dizer, a nova figura englobaria e alargaria o conceito da infração penal anterior.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, o réu atentou contra a vítima por diversas vezes, como se verá a seguir.

Além disso, a nova figura exige a representação da vítima, providência devidamente observada (fls. 07 e 45).

Não obstante o reenquadramento típico da conduta, é caso de se manter a sanção

anteriormente prevista, porquanto mais benéfica ao réu.

Nesse sentido, entendimento do C. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAÇÃO PENAL. ABSOLUÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ABOLITIO CRIMINIS NÃO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA. AGRAVO DESPROVIDO. Nos moldes do reconhecido no parecer ministerial, "os fatos do caso ocorreram em junho de 2018, momento em que a aludida contração penal de perturbação da tranquilidade ainda não havia sido retirada da Lei das Contrações Penais (art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.888/41) pela Lei nº. 14.132/21, que entrou em vigência apenas em 01/04/2021, quando a conduta acabou sendo reinserida no art. 147-A do Código Penal, com a seguinte dicção: "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", prática agora também conhecida como stalking" (e-STJ, fl. 196). Incide ao caso o princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis. Importante destacar que tal ato teria ocorrido pelo menos duas vezes, não se tratando de fato isolado como defensivo pelo agravante. Agravo desprovido. (AgRg no HC 680.738/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou evidenciada por intermédio dos prints, retratando mensagens via aparelho celular, de fls. 16/19, a par da prova oral.

A autoria não comporta dúvidas.

A análise coligida dos depoimentos colhidos no caderno investigativo e produzidos na fase do contraditório autoriza concluir pela responsabilidade penal do agente. Vejamos.

Osana Aparecida da Silva, vítima, narrou que estava separada do réu há um ano, mas ele era acostumado a abordá-la na saída de seu trabalho, em lanchonete e, naquela data não foi diferente. Estava no salão, enquanto ele a esperava do lado de fora. Ao sair com sua amiga Verônica, o acusado se aproximou dizendo que queria conversar com ela, tendo lhe dito, em resposta, que já tinha "sido resolvido" e não havia mais o que conversarem. Então, o réu insistiu, entrando com ela, no lugar de Verônica, dentro do carro. Ela saiu do veículo, mas ele permaneceu no interior. Em certo momento, ele também saiu do veículo, mas insistia em conversar. Então, ela retornou para dentro do veículo e foi embora na companhia de Verônica, se dirigindo até à Delegacia para registrar ocorrência e postular a concessão de medidas protetivas. O acusado a perturbava cerca de duas vezes na semana.

Verônica Maria da Silva relatou que estava saindo do salão de beleza com a vítima, momento em que avistaram o acusado, que estava do outro lado da rua e se aproximou delas para conversar com Osana, mas ela não desejava dialogar. Nisso, ambos entraram no veículo e depois saíram, não sabendo o que conversaram. A depoente permaneceu esperando, nervosa com a situação.

Interrogado, MARCOS disse que estava saindo de seu trabalho e, ao passar pelo local, encontrou com a vítima e sua prima, proprietária do salão. Parou para conversar com ela, pois não conseguia ver sua filha e queria resolver a situação. Não houve agressão. Chegaram a entrar no carro para conversarem. Ao sair do carro, ela disse que chamaria a polícia tendo ele dito que não precisava, pois estava indo

embora. Saiu nervoso do veículo, mas não ameaçou a vítima.

Pois bem.

Este é o contexto instalado nos autos.

Incontroverso nos autos que réu e vítima mantiveram um relacionamento amoroso e, na data dos fatos, estavam separados há um ano.

O réu, pelo teor das mensagens de fls. 16/19, não se conformava com a ruptura, insistindo para que reatassem o relacionamento amoroso.

Ademais, adotava comportamento fiscalizatório quanto à vida pessoal da vítima, monitorando suas saídas do trabalho e seus momentos de lazer, de forma que seu encontro com ela, naquela data, nada teve de casual, porquanto ele a aguardava do lado de fora do salão de beleza, sabendo que ela estava ali.

Conforme se observa da prova oral colhida, a vítima foi enfática ao relatar que após o término do relacionamento o réu passou a lhe perseguir reiteradamente na rua, esperando-a sair de seu trabalho e encontrando-a em locais públicos, fazendo questão de se mostrar presente e frisar que conhecia toda sua rotina. Ao menos duas vezes na semana a perturbava e na data dos fatos não foi diferente. Abordou-a para estabelecer um diálogo forçado, mesmo sabendo que ela não desejar manter conversas junto a ele.

A testemunha Verônica bem destacou que o réu se aproximou dela e da vítima assim que ambas saíram do salão e se dirigiu até Osana, se sentando no banco do veículo mesmo sem ser convidado e a contragosto da vítima, tudo para conversar com ela.

A reiteração de comportamentos indesejáveis, caracterizadores da situação incômoda, somente cessou a partir de quando a vítima postulou medidas protetivas, deferidas judicialmente.

Desta forma, houve a prática reiterada de perturbação em desfavor da vítima, em contexto configurador de violência doméstica e familiar contra a mulher, que lhe causou prejuízos em suas esferas de liberdade e privacidade, porquanto o acusado insistia em obsidiar e perturbar a vítima de forma constante e incessante.

E a alegação de buscar um diálogo para tentar visitar a filha deles é falso pretexto para monitorar a vítima e estar sempre próximo à ela, lembrando que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar aquela finalidade.

Assim, configurado o crime, anoto, in casu, a aplicação ao princípio da continuidade normativo-típica, amoldando-se, portanto, às elementares constantes da descrição típica do novo crime previsto no artigo 147-A do Código Penal.

Nesse diapasão, segundo CLEBER MASSON: “De fato, não há falar em abolitio criminis nas hipóteses em que, nada obstante a revogação formal do tipo penal, o fato criminoso passa a ser disciplinado perante dispositivo legal diverso. Nesses casos, verifica-se a incidência do princípio da continuidade normativa (ou da continuidade típico-normativa), operando-se simplesmente a alteração geográfica (ou topográfica) da conduta ilícita” (Direito Penal: parte geral - arts. 1º a 120, vol. 1, 13. ed., Editora Método, p. 233).

Nesse sentido, ainda, são os julgados recentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Apelação. Contravenção penal. Perturbação da tranquilidade no âmbito da violência

doméstica e familiar contra a mulher. [...] Mesmo com a entrada em vigor da Lei 14.132/2021, que acrescentou o artigo 147-A no Código Penal e revogou o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, a conduta praticada pelo recorrente ainda deve ser punida. Isto porque, não houve abolitio criminis. A conduta permanece proibida, somente tendo sido deslocada para outro tipo penal. Aplica-se ao caso, portanto, o princípio da continuidade normativo-típica. Considerando que a nova legislação é mais prejudicial ao apelante, a legislação anterior ainda é aplicada, mesmo com sua revogação, pela ultratividade da norma penal mais benéfica. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação Criminal 1501242-61.2019.8.26.0063; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barra Bonita - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL Contravenção penal de perturbação da tranquilidade Reconhecimento da abolitio criminis Apelo do Ministério Público Abolitio criminis não configurado Perturbação da tranquilidade e da liberdade da vítima Reiteração evidenciada Aplicação do princípio da continuidade normativo-típica Anulação da sentença e remessa ao Juízo de origem para a apreciação do mérito.” (TJSP; Apelação Criminal 1502774- 90.2020.8.26.0530; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021).

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

PASSO À DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal e da análise de sua Certidão de Eventos (fls. 57/58), verifico que o acusado ostentava maus antecedentes.

Com efeito, verifica-se que o réu possui uma condenação com trânsito em julgado anterior à prática delitiva narrada nestes autos, superando o período quinquenal depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, que lhe afastara a reincidência (cf. certidão de fl. 57).

Apoiado em forte corrente jurisprudencial, com destaque para àquela do C. STJ, tenho sustentado que: “O conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.” (HC n. 171.212/DF, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20.08.2015).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA MAJORADA NA PRIMEIRA FASE UTILIZANDO MAUS ANTECEDENTES E NA SEGUNDA A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECURSO DE LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O TÉRMINO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E A DATA DO NOVO CRIME. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO VÁLIDO. (...) (STJ, T5 – Quinta Turma, Habeas Corpus 412.585/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 26.09.2017)

REVISÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO.

HIPÓTESE QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA LEGAL. SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE NÃO CONTRARIARAM TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL NEM A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. (...)

3. A condenação, cuja sentença transitou há mais de 05 (cinco) anos, embora não sirva para caracterizar a circunstância agravante da reincidência, por força do art. 64, I, do Código Penal, serve, sim, para caracterizar o conceito de maus antecedentes criminais, nos termos do art. 59, "caput", do Código Penal, exasperando, de tal arte, a pena-base. Nesse sentido a Doutrina de Alberto Silva Franco e Victor Eduardo Rios Gonçalves e a jurisprudência do STF (RHC 116.070/RJ - Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22.04.14; AP 503/PR - Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.13 e RHC 106.814/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.02.11). (...) (TJSP, 2º Grupo de Dir. Criminal, Rev. Criminal nº 0010912-03.2016.8.26.0000. Rel. Des. Airton Vieira, 12.12.2017).

E, a meu sentir, tais efeitos judiciais desabonadores perdurarão para fins de maus antecedentes pelo prazo de novos 05 (cinco) anos, contados do término do aludido período depurador.

Por tal razão, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal, eis que o réu se prevaleceu da relação doméstica e familiar, cujo aumento será de 1/6 (um sexto).

Inexistem causas de aumento e/ou diminuição.

O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia CONDENAR o réu MARCOS ROBERTO LEITE, qualificado nos autos, a cumprir pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime aberto, como incurso no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, aplicado ultrativamente, na forma do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de o agente ter se prevalecido das relações domésticas (Súmula nº 588, STJ).

Atento à quantidade de pena imposta e regime prisional fixado, ausentes, ainda, os fundamentos ensejadores da custódia cautelar (art. 312, caput e §2º, do CPP), permito-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, §1º, do CPP).

Intime-se a vítima acerca do teor da presente (art. 201, §2º, CPP), para conhecimento.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.R.I.C.

Amparo, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA